

1500325-54.2022.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Tal entendimento decorreu do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Vila Nova, Rio Claro - 13506-547 - SP

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo nº:

1500325-54.2022.8.26.0510 - 2022/000092

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER MEIRELLES SILVA

Réu Preso

Em 13 de dezembro de 2022, às 13:38 horas, excepcionalmente, em ambiente virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Sr. Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rio Claro, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência, presentes a representante do Ministério Público, Dra. Renata Maria Cruz Destro, o Réu EDER MEIRELLES SILVA, e a DD. Defensora Pública, Dra. Maria Auxiliadora Santos Essado.

Presentes: as testemunhas comuns Walter Muccillo e Eduardo Samir Zanini.

Iniciada a audiência virtual foram ouvidas as testemunhas arroladas, após interrogando-se o acusado.

Deliberação do Juízo: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual. Aos debates da causa.

Manifestação do Ministério Público: MM. Juiz: (manifestação colhida por meio do sistema audiovisual).

Manifestação da Defesa: MM. Juiz: (manifestação colhida por meio do sistema audiovisual).

Deliberação do Juízo: Passo à prolação da sentença. Vistos. EDER MEIRELLES SILVA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 03 de fevereiro de 2.022, por volta das 13:15, na Avenida M 29, com a Rua M 8, Jardim Chervezon, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia

consigo 13 (treze) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado de 4,97 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo de constatação de fls. 23/25, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia e seu aditamento no dia 25 de outubro de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado. Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação de regime aberto, em caso de reconversão, operando-se, ainda, o perdimento da importância em dinheiro apreendida. A ilustre Defensora Pública, a sua vez, inicialmente pugnando pelo reconhecimento do princípio da insignificância, dada a diminuta quantidade de entorpecente apreendido, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. No mérito, dizendo insuficiente a prova produzida no que diz com a posse e a destinação mercantil do entorpecente, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação pela imputação inicial, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão inicialmente externada, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em grau máximo, importando em regime prisional inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, facultando-se a interposição de recurso em liberdade, com a restituição da quantia apreendida. Em síntese, o RELATÓRIO. DECIDO. Procede a pretensão acusatória. Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo o entorpecente descrito na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 53/55, com resultado positivo para cocaína. Sustenta-se em favor do acusado que a conduta seria materialmente atípica, em função do princípio da insignificância, porquanto diminuta a quantidade de entorpecente apreendida. No entanto, respeitado o entendimento exposto, além de não se tratar de quantidade inexpressiva, não se mostraria possível o reconhecimento do princípio da insignificância diante da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes, com violação de bem juridicamente relevante, consistente na segurança e saúde pública, tanto mais quando se verifica que esta prática foi considerada como equiparada a outros delitos de natureza hedionda. A propósito: "CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com fundamento no princípio da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de crime de perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 318.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)". Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Inicialmente ouvido, o acusado admitiu a prática do delito que lhe é irrogado na denúncia, observando que a quantia em dinheiro também apreendida em seu poder, além de treze porções de crack, decorria da atividade ilícita. Em juízo, observou que estava no local, onde manteve

contato com um terceiro, mas para adquirir o entorpecente que foi apreendido em seu poder, negando a prática do delito. Todavia, mais se harmoniza com o conjunto probatório a confissão inicialmente externada. De fato, os Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, afirmaram que à época estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado mantendo contato com um indivíduo, que se encontrava em uma bicicleta, tendo empreendido fuga quando da aproximação da guarnição. Foi o acusado em seguida abordado, ainda segundo o exposto, apreendendo-se com ele treze porções de crack, além de certa quantia em dinheiro, admitindo que estava realizando o comércio ilícito e que o valor apreendido decorria desta atividade. Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Deste modo, tem-se não apenas demonstrada a posse do entorpecente, mas também revelam as circunstâncias a sua destinação mercantil, assim porque o acusado foi avistado em local de venda de entorpecente, mantendo contato com terceiro, apreendendo-se em seu poder diversas porções de crack, além de certa quantia em dinheiro, admitindo a realização do comércio ilícito. Assim, todos esses elementos probatórios permitem seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial. Por fim, considerando que os valores apreendidos decorriam desta atividade ilícita, sobre os mesmos deve incidir a pena de perdimento. Isto considerando, passo à dosagem da pena. Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de considerar a circunstância atenuante da confissão espontânea, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ). Entretanto, a pena-base cominada deve ser reduzida, em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito. O acusado é primário, não ostenta condenação criminal anterior, não havendo indicação suficiente de que estivesse já dedicado à atividade criminosa, de tal modo que, também em função da pouca quantidade de entorpecente, deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico

privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa". Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016). Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06). Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo. Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo. Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado EDER MEIRELLES SILVA à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei

nº 11.343/06. Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto. Diante da pena cominada, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado, ficando restabelecida a liberdade provisória, com as medidas cautelares impostas. Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei. Sentença publicada em audiência. Saem as partes intimadas, renunciando a ilustre Promotora de Justiça e a DD. Defensora Pública ao direito de recurso. Sentença transitada em julgado nesta data. Efetuem-se as anotações e comunicações pertinentes. Nada mais. Anoto que a audiência foi realizada pelo Microsoft TEAMS, com importação da mídia para o sistema informatizado SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Eu, Flávia Alessandra Arruda Z. Vitorino, Escrevente Técnico Judiciário., digitei e subscrevi.